

บทที่ ๑๙

คดีปกครองเกี่ยวกับการพัสดุ

๑. การจัดทำประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้าง

๑.๑ การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุที่ต้องการซื้อหรืองานที่ต้องการจ้าง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคา

เมื่อระเบียบว่าด้วยการพัสดุมิได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาไว้ หน่วยงานทางปกครองจึงมีดุลพินิจในการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาได้โดยคำนึงถึงความโปร่งใส การเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และความสามารถในการรับงานของผู้ขายหรือผู้รับจ้างประกอบด้วย เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าประกาศประกวดราคาพิพาทเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์กลางระบบค้นหาและการจัดการข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินงบประมาณประมาณ ๒๐ ล้านบาท อันเห็นได้ว่าเป็นพัสดุที่มีความสลับซับซ้อน และมีวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อสูง การที่หน่วยงานทางปกครองกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาไว้ให้ต้องเป็นผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่เคยมีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ให้กับองค์กรภาครัฐหรือเอกชนจำนวน ๑ แห่ง เป็นอย่างน้อย ซึ่งมีมูลค่าของโครงการไม่น้อยกว่า ๕ ล้านบาท ก็เพื่อให้เป็นข้อบ่งชี้ในเบื้องต้นว่า ผู้เสนอราคาดังกล่าวมีประสบการณ์และความชำนาญเพียงพอที่จะขายครุภัณฑ์ศูนย์กลางระบบค้นหาและการจัดการข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติที่สามารถใช้งานได้ สมวัตถุประสงค์ คู่มีค่ากับเงินงบประมาณที่ต้องใช้ไปในการจัดหาพัสดุดังกล่าว และภายในเวลาอันสมควร ดังนั้น การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาในลักษณะข้างต้นไว้ในประกาศประกวดราคา จึงไม่อาจถือเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตามอำเภอใจ หากแต่มีเหตุผลอันควรค่าแก่การรับฟังอย่างยิ่ง กรณีจึงมิได้มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม อันเป็นเหตุให้เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์กลางระบบค้นหาและการจัดการข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาไว้ในขอบเขตของงาน (TOR) ว่า จะต้องมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ให้กับองค์กรภาครัฐหรือเอกชนจำนวน ๑ แห่ง เป็นอย่างน้อย ซึ่งมีมูลค่าของโครงการไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ในกิจการรับจ้าง ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง เป็นที่ปรึกษา และบำรุงรักษาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความประสงค์จะเข้าร่วมการประกวดราคาดังกล่าว เห็นว่าการกำหนดคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาข้างต้นมีลักษณะเป็นการกีดกันและไม่เปิดโอกาสให้กับผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์การทำงานมาก่อน ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถซื้อเอกสารประกวดราคาเพื่อเข้าร่วมการประกวดราคาครั้งนี้ได้ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนการกำหนดคุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิเสนอราคาในข้อกำหนดแนบท้ายขอบเขตของงาน (TOR) ที่พิพาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมมิได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาไว้ ส่วนราชการจึงมีดุลพินิจในการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาได้ตามที่เห็นสมควร โดยคำนึงถึงความโปร่งใส การเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และความสามารถในการรับงานของผู้ขายหรือผู้รับจ้างประกอบด้วย

เมื่อพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ศูนย์กลางระบบค้นหาและการจัดการข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติจำนวน ๑ ระบบ อันเป็นพัสดุที่ผู้ถูกฟ้องคดีจัดหาในคดีนี้แล้ว เห็นได้ว่า เป็นพัสดุที่มีความสลับซับซ้อน มีวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อสูงถึง ๒๐,๓๓๓,๐๐๐ บาท ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะได้พัสดุที่มีคุณภาพ สามารถใช้งานได้ สมวัตถุประสงค์ คำนึงถึงเงินงบประมาณที่ต้องใช้ไปในการจัดหาและภายในเวลาอันสมควร วิทยุชนเช่นผู้ถูกฟ้องคดีจึงขอที่จะพิจารณาจัดซื้อพัสดุที่ต้องการจากผู้ประกอบการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่มีประสบการณ์และความชำนาญสูงพอสมควร เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุดังกล่าวจากผู้ประกอบการที่ไม่มีประสบการณ์และความชำนาญเพียงพอ ย่อมเป็นการสุ่มเสี่ยงต่อการได้มาซึ่งพัสดุที่ไม่มีคุณภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ หรือได้พัสดุที่ล่าช้ากว่าเวลาอันสมควร การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ประกาศ



ประกวดราคาพิพาทโดยแบ่งบุคคลผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ออกเป็นสองประเภท ได้แก่ ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่เคยมีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ให้กับองค์กรภาครัฐหรือเอกชนจำนวน ๑ แห่ง เป็นอย่างน้อย ซึ่งมีมูลค่าของโครงการไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมกับแนบรายชื่อทีมที่รับผิดชอบซึ่งต้องมีประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพ ประเภทหนึ่ง กับผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์อีกประเภทหนึ่ง แล้วกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาในการประกวดราคาพิพาทที่จะต้องเป็นผู้ประกอบกิจการตามประเภทแรก ก็เพื่อเป็นข้อบ่งชี้ในเบื้องต้นว่า ผู้เสนอราคายาวนั้นมีประสบการณ์และความชำนาญเพียงพอที่จะขายครุภัณฑ์ศูนย์กลางระบบค้นหาและการจัดการข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติ จำนวน ๑ ระบบที่สามารถใช้งานได้สมดังวัตถุประสงค์ คำนวณกับเงินงบประมาณที่ต้องใช้ไปในการจัดหาและภายในเวลาอันสมควร กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตามอำเภอใจ หากแต่มีเหตุผลอันควรค่าแก่การรับฟังเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นข้อกำหนดข้างต้นจึงมิได้มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม อันเป็นเหตุให้เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๔๓/๒๕๕๙)

เมื่อพัสดุดตามโครงการสอบราคาจ้างพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพภาคเอกชน เป็นพัสดุดที่มีความสลับซับซ้อนและมัวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อสูง การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาที่จะต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างตามที่สอบราคา ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๙๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งต้องมีผลงานการพัฒนาโปรแกรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นแบบ **Web Base Application** และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการในวงเงินงบประมาณไม่ต่ำกว่า ๙๐๐,๐๐๐ บาท ต่อหนึ่งสัญญา ก็เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้เสนอราคายาวนั้นมีประสบการณ์และความชำนาญเพียงพอที่จะรับจ้างพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพภาคเอกชนให้สามารถใช้งานได้สมดังวัตถุประสงค์ คำนวณกับเงินงบประมาณที่ต้องใช้ไปในการจัดหาและภายในเวลาอันสมควร จึงไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตามอำเภอใจ หากแต่มีเหตุผลอันควรค่าแก่การรับฟังเป็นอย่างยิ่ง ส่วนการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาว่าต้องมี

ทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ชำระเต็มมูลค่า) ก็เพื่อให้มั่นใจได้ว่า หากจำเป็นต้องมีการใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายที่ได้รับจากการที่ผู้รับจ้างประพาศผิดสัญญาเพิ่มเติมจากค่าเสียหายที่บังคับเอาจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างยังจะมีทรัพย์สินให้บังคับชำระหนี้ค่าเสียหายได้ ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว จึงไม่อาจถือเป็นการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาตามอำเภอใจ หากแต่มีเหตุผลอันควรค่าแก่การรับฟังอย่างยิ่งเช่นเดียวกัน ประกาศสอบราคาจ้างที่กำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคาตามลักษณะดังกล่าวข้างต้น จึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศสอบราคาจ้างพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพภาคเอกชน โดยมีข้อกำหนดว่า ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกันกับที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๙๐๐,๐๐๐ บาท และตามเอกสารสอบราคาจ้างในส่วนที่เกี่ยวกับขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาว่าต้องเป็นนิติบุคคลซึ่งมีผลงานการพัฒนาโปรแกรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นแบบ Web Base Application และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ โดยมีผลงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า ๙๐๐,๐๐๐ บาท ต่อหนึ่งสัญญา อีกทั้งต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ชำระเต็มมูลค่า) บริษัท ช. (ผู้ฟ้องคดี) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ในกิจการรับจ้างออกแบบพัฒนา ติดตั้ง เป็นที่ปรึกษาและบำรุงรักษาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ มีความประสงค์จะเข้าร่วมเสนอราคาตามประกาศดังกล่าว จึงไปขอรับเอกสารสอบราคาข้างต้น แต่เมื่อตรวจสอบข้อกำหนดตามประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาพิพาทแล้วเห็นว่า การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคามีลักษณะเป็นการกีดกันผู้ฟ้องคดีและผู้ประกอบการรายใหม่ อันเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถยื่นเอกสารเสนอราคาตามประกาศดังกล่าวได้ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนข้อกำหนดตามประกาศสอบราคาพิพาท และให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการสอบราคาจ้างใหม่ต่อไป

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาไว้ ดังนั้น ส่วนราชการจึงมีดุลพินิจในการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาได้ตามที่เห็นสมควร โดยคำนึงถึงความโปร่งใส การเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และความสามารถในการรับงานของผู้ขายหรือผู้รับจ้าง



แม้ประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาจ้างพิพาทในส่วนที่เกี่ยวกับขอบเขตของงาน (TOR) จะแบ่งบุคคลผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ออกเป็นสองประเภท ได้แก่ ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ประเภทนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างตามที่สอบราคาจ้างซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีผลงานการพัฒนาโปรแกรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นแบบ Web Base Application ซึ่งเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ในประเทศไทย ไม่ต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ต่อหนึ่งสัญญา และมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ชำระเต็มมูลค่า) ประเภทหนึ่ง กับผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์อื่นอีกประเภทหนึ่ง และปฏิบัติต่อผู้ประกอบกิจการแต่ละประเภทดังกล่าวแตกต่างกัน โดยผู้ประกอบกิจการประเภทแรกมีสิทธิเสนอราคาตามประกาศสอบราคาจ้างพิพาท ส่วนผู้ประกอบกิจการประเภทที่สองไม่มีสิทธิเสนอราคาก็ตาม แต่เมื่อได้พิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพภาคเอกชนตามประกาศสอบราคาและขอบเขตของงาน (TOR) ที่พิพาทในกรณีนี้แล้ว เห็นได้ว่า พัสต์ที่ต้องการซื้อเป็นพัสต์ที่มีความสลับซับซ้อน และมีวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อมากถึง ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท ดังนั้นเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้พัสต์ที่มีคุณภาพ สามารถใช้งานได้สมวัตถุประสงค์ คุ่มค่ากับเงินงบประมาณที่ต้องใช้ไปในการจัดหา และภายในเวลาอันสมควร ผู้ถูกฟ้องคดีจึงชอบที่จะพิจารณาจัดซื้อพัสต์ที่ต้องการจากผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่มีประสบการณ์และความชำนาญสูงพอสมควร การจัดซื้อพัสต์ดังกล่าวจากผู้ประกอบกิจการที่ไม่มีประสบการณ์และความชำนาญเพียงพอย่อมเป็นการเสี่ยงต่อการได้มาซึ่งพัสต์ที่ไม่มีคุณภาพ ไม่สามารถใช้งานได้สมวัตถุประสงค์ หรือได้พัสต์ที่ล่าช้ากว่าเวลาอันสมควร การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาในประกาศสอบราคาจ้างพิพาท โดยกำหนดว่าผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาจ้างดังกล่าวซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท และในเอกสารสอบราคาจ้าง ในส่วนที่เกี่ยวกับขอบเขตของงาน (TOR) ที่กำหนดว่าผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานการพัฒนาโปรแกรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นแบบ Web Base Application และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือในประเทศไทย โดยมีผลงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ต่อหนึ่งสัญญา โดยมีหนังสือรับรองจากคู่สัญญาพร้อมระบุชื่อ/สถานที่ของคู่สัญญาและมีการใช้งานอยู่จริงหรือเอกสารที่จะตรวจสอบได้ยื่นพร้อมเอกสารเสนอราคา

และต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ชำระเต็มมูลค่า) โดยมีหลักฐานการจดทะเบียนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกให้หรือรับรองให้ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันที่ยื่นซอง อันเป็นข้อบ่งชี้ในเบื้องต้นว่า ผู้เสนอราคายานั้นมีประสบการณ์และความชำนาญเพียงพอที่จะรับจ้างพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพภาคเอกชน สามารถใช้งานได้สมวัตถุประสงค์ คำนวณกับเงินงบประมาณที่ต้องใช้ไปในการจัดหาพัสดุดังกล่าว และภายในเวลาอันสมควร จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้ประกอบการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตามอำเภอใจ หากแต่มีเหตุผลอันควรค่าแก่การรับฟังเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ แม้จะเป็นความจริงว่า ในการทำสัญญาพิพาทผู้ถูกฟ้องคดีย่อมจะเรียกให้ผู้รับจ้างจัดให้มีหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา เพื่อว่าในกรณีที่ผู้รับจ้างประพฤติดิตสัญญาเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเอาจากผู้รับจ้างโดยบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ก็ตาม แต่การบังคับเอาจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็อาจจะไม่ครอบคลุมความเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับจากการที่ผู้ขายประพฤติดิตสัญญา จนเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขายเพิ่มขึ้น ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาว่า ผู้เสนอราคา... ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ชำระเต็มมูลค่า) ซึ่งเป็นที่เห็นได้ชัดว่าเป็นไปเพื่อให้มั่นใจได้ว่า หากผู้ถูกฟ้องคดีจำเป็นต้องใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายที่ได้รับจากการที่ผู้รับจ้างประพฤติดิตสัญญาเพิ่มเติมจากค่าเสียหายที่ได้บังคับเอาจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างยังจะมีทรัพย์สินให้บังคับชำระหนี้ค่าเสียหายได้ จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาตามอำเภอใจ หากแต่มีเหตุผลอันควรค่าแก่การรับฟังเป็นอย่างยิ่งเช่นกัน กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาตามประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาที่พิพาทในส่วนที่เกี่ยวกับขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม อันเป็นเหตุให้เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๐๒๓/๒๕๕๙)

การจะรับฟังว่าการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องปรากฏว่าหน่วยงานทางปกครองได้ใช้ดุลพินิจจำกัดคุณสมบัติของผู้จะเข้าเสนอราคาโดยเห็นได้อย่างชัดเจนว่า การจำกัดคุณสมบัติเช่นนั้นไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างแน่แท้หรือเกินความจำเป็น และการจำกัดเช่นนั้นทำให้สาระสำคัญของหลักการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือโปร่งใสต้องเสียไป เมื่อการที่กรมการจัดหางานประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ทะเบียนคนหางานไปทำงาน



ต่างประเทศ โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี ต้องมีผลงานพัฒนาระบบสารสนเทศมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ สัญญา มูลค่าไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท และต้องมีบุคลากรซึ่งมีคุณสมบัติและตำแหน่งที่กำหนด เป็นไปเพื่อให้มีโอกาสได้ผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เพื่อเป็นหลักประกันความสำเร็จของงาน และหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง แม้อาจจะทำให้ผู้ประกอบการส่วนหนึ่งขาดคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมประกวดราคาก็ตาม แต่เมื่อการกำหนดคุณสมบัติข้างต้นยังคงไว้ซึ่งหลักการที่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาระหว่างผู้ประกอบการ อีกทั้งยังได้มีการประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคาให้ผู้สนใจทราบ โดยเปิดเผยตามที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการพัสดุ การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาข้างต้น จึงไม่ใช่การใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

กรมการจัดหางาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประสงค์จะจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ทะเบียนคนหางาน (Labour Bank) เพื่อคนหางานไปทำงานต่างประเทศด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ระบบ จึงได้ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ทะเบียนคนหางาน (Labour Bank) เพื่อคนหางานไปทำงานต่างประเทศด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของผู้ถูกฟ้องคดีและของกรมบัญชีกลาง ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการพัฒนาระบบและซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สนใจเข้าร่วมเสนอราคาตามประกาศประกวดราคาจ้างดังกล่าว แต่เมื่อตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแล้วเห็นว่า ข้อ ๕ ของประกาศดังกล่าวซึ่งกำหนดว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานด้านคอมพิวเตอร์ หรือติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วงดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยมีหลักฐานการจดทะเบียนซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ออกให้หรือรับรองให้ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันยื่นซองข้อเสนอการประกวดราคา และข้อ ๖ ซึ่งกำหนดว่า ต้องมีผลงานเกี่ยวกับโครงการด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศหรือระบบ Radio-Frequency Identification (RFID) ให้แก่หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจอย่างน้อย ๑ สัญญา โดยมีมูลค่าไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท และจะต้องมีหนังสือรับรองจากคู่สัญญาโดยตรงสำหรับผลงานดังกล่าว พร้อมสำเนาฉบับสัญญาแนบมาพร้อมกับข้อเสนอด้านเทคนิค ทั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีของสวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบโดยตรงจากคู่สัญญาตามหนังสือรับรองที่เสนอนั้น รวมทั้งข้อ ๗ ซึ่งกำหนดว่า ต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีตำแหน่งและคุณสมบัติตามภาคผนวก ก. โดยต้องแสดงหลักฐานยืนยัน

การเข้าร่วมเพื่อประกอบการพิจารณา มีผลเป็นการตัดสิทธิผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหม่และรายย่อยที่ยังไม่มีผลงานและบุคลากรที่มีตำแหน่งหรือคุณสมบัติตามที่กำหนดไม่ให้เข้าร่วมเสนอราคา อันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาตามประกาศประกวดราคาดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในการจัดซื้อและจัดจ้างของส่วนราชการหากมีความจำเป็นต้องจำกัดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาไว้เป็นการเฉพาะ เช่น ประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมา สมรรถภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ และโรงงาน ฐานะการเงิน ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อและจัดจ้างนั้นมีอำนาจใช้ดุลพินิจในการจำกัดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาได้ เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการในการจัดซื้อและจัดจ้าง ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๕ ทวิ วรรคหนึ่ง^๑ ประกอบกับข้อ ๓๐ วรรคหนึ่ง^๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ อย่างไรก็ตาม การใช้ดุลพินิจในทางจำกัดคุณสมบัติดังกล่าวจะต้องดำเนินการตามหลักสุจริตเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคากันอย่างเป็นธรรม เพื่อให้ทางราชการได้รับประโยชน์สูงสุดจากการแข่งขันราคา ซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่ล้วนสอดแทรกอยู่ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ ทั้งฉบับ

^๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑

ข้อ ๑๕ ทวิ การจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนของการจัดหา ต้องดำเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน เว้นแต่กรณีที่มีลักษณะเฉพาะอันเป็นข้อยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

^๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙

ข้อ ๓๐ ส่วนราชการใดประสงค์จะคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อและการจ้างให้กระทำในกรณีที่ต้องจำกัดเฉพาะผู้ที่มีความสามารถ โดยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยเปิดเผยพร้อมทั้งส่งให้ กวพ. ด้วย

ในการดำเนินการคัดเลือก ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องจัดทำรายงานเสนอขออนุมัติหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ พร้อมด้วยเอกสารคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (๑) เหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องทำการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น
- (๒) ประเภท วงเงิน และรายละเอียดของพัสดุหรืองานที่จะต้องซื้อหรือจ้าง
- (๓) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ซึ่งเป็นเกณฑ์ความต้องการขั้นต่ำ เช่น ประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมา สมรรถภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ และโรงงาน ฐานะการเงิน เป็นต้น
- (๔) หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก



เมื่อพิจารณาเหตุผลความจำเป็นที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าเป็นเหตุให้ต้องกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาไว้ดังกล่าว ว่าเป็นเพราะการจัดจ้างตามโครงการมีความยุ่งยากซับซ้อน และต้องสามารถใช้งานร่วมกับระบบงานอื่น ๆ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ ผู้รับจ้างจึงต้องมีความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญในเทคโนโลยี การกำหนดอายุการทำงานและผลงานที่เป็นงานประเภทเดียวกันจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อผลสำเร็จของการดำเนินงาน และการกำหนดตำแหน่งและคุณสมบัติของบุคลากรก็เป็นไปเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีมั่นใจว่า ผู้รับจ้างมีบุคลากรและทีมงานที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะทำให้งานด้านเทคนิคเฉพาะสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน เห็นว่า เมื่อหน่วยงานของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลกระบวนการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ มีงานที่ดีมีรายได้ที่เหมาะสม ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างหรือบริษัทจัดหางาน และป้องกันไม่ให้ถูกหลอกจากสายหรือนายหน้า เพื่อให้การสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการบริการตามภารกิจหลักของผู้ถูกฟ้องคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ทะเบียนคนหางาน (Labour Bank) เพื่อคนหางานไปทำงานต่างประเทศ เช่น ระบบ Radio-Frequency Identification (RFID) มาใช้ในการเก็บข้อมูลคนหางานที่เดินทางกลับจากการไปทำงานต่างประเทศแบบอัตโนมัติ การพัฒนาเว็บไซต์สองภาษา (ไทย/อังกฤษ) ให้นายจ้างสามารถเข้ามาคัดเลือกคนหางานจากฐานข้อมูล (Labour Bank) ได้โดยตรงจากระบบอินเทอร์เน็ต การใช้ระบบ Web Application เป็นช่องทางในการตรวจสอบข้อมูลคนหางานจากอินเทอร์เน็ต และการพัฒนาระบบเพื่อใช้ในการเสนอข้อมูลข่าวสารการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศสำหรับหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง เมื่อการจะรับฟังว่าการกำหนดหลักเกณฑ์ที่เป็นข้อจำกัดในคดีนี้เป็นสิ่งที่ไม่ชอบหรือเป็นการใช้ดุลพินิจไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้ดุลพินิจจำกัดคุณสมบัติของผู้จะเข้าประกวดราคาโดยเห็นได้อย่างชัดแจ้งว่า การจำกัดคุณสมบัติเช่นนั้นไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างแน่แท้หรือเกินความจำเป็น และการจำกัดเช่นนี้ทำให้สาระสำคัญของหลักการการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือโปร่งใสต้องเสียไป ซึ่งตามกรณีนี้ปรากฏว่าการกำหนดข้อจำกัดเช่นนั้นทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีโอกาที่จะได้ผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เพื่อเป็นหลักประกันความสำเร็จของงานและหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในภายหลังตามที่กล่าวไว้ข้างต้น อีกทั้ง การกำหนดคุณสมบัติดังกล่าวก็ยังคงไว้ซึ่งหลักการที่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาระหว่างผู้ประกอบการซึ่งแม้ว่าจะทำให้ผู้ประกอบการส่วนหนึ่งขาดคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมประกวดราคาก็ตาม แต่การที่จะให้ผู้ถูกฟ้องคดีผ่อนคลายหรือแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้รับจ้างให้ผู้ฟ้องคดีเข้าเสนอราคาได้นั้น ต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน และโดยที่ระบบสารสนเทศ

ของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นงานที่มีความสำคัญ มีประโยชน์ต่อแรงงานที่ต้องการไปทำงานในต่างประเทศ นายจ้าง ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้เกิดผลสำเร็จให้สามารถใช้งานได้จริงเต็มประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถูกฟ้องคดี จึงจำเป็นที่จะต้องหาผู้รับจ้างที่มีความรู้ ประสบการณ์และความชำนาญในเทคโนโลยี หากได้ผู้รับจ้างที่ไม่มีศักยภาพแล้วอาจต้องมีการลองผิดลองถูกหรือใช้เวลาในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาโปรแกรม การพัฒนาระบบดังกล่าวอาจเสียไปโดยเปล่าประโยชน์เนื่องจากเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้ และย่อมเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการดำเนินงานของผู้ถูกฟ้องคดี และในกรณีการป้องกันความเสียหายดังกล่าวไม่สามารถนำเรื่องหลักคำประกันของร้อยละ ๕ มาบังคับใช้ได้ เนื่องจากการยึดหลักประกันของไม่ใช่จุดประสงค์หรือความมุ่งหมายในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบของผู้ถูกฟ้องคดี ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยเปิดเผยตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ กำหนดแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคาในลักษณะเช่นว่านั้นจึงไม่อาจรับฟังว่าเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และถือว่าเหตุผลความจำเป็นที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างเป็นเหตุผลที่ควรค่าแก่การรับฟัง เนื่องจากการกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้เสนอราคาไม่ได้มีข้อจำกัดเกี่ยวกับถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองแต่อย่างใด หากผู้ฟ้องคดีหรือผู้ประกอบการรายใดมีประสบการณ์การประกอบกิจการ มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติและตำแหน่งตามที่กำหนด และมีผลงานพร้อมสัญญาการซื้อขายในด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศจากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนตามที่กำหนด ก็สามารถเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาในครั้งนี้ได้ การกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวจึงไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม หรือเป็นการจำกัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีตามมาตรา ๓๐^๓ และมาตรา ๔๓^๔

^{๓-๔} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๓๐ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน

ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทำมิได้

มาตรการที่รัฐกำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม

มาตรา ๔๓ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม

การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะ

